

1004462-66.2018.8.26.0126

Classe: Embargos à Execução Fiscal

Assunto: Extinção da Execução

Magistrado: Ayrton Vidolin Marques Júnior

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: SAF - Serviço de Anexo Fiscal

Data de Disponibilização: 29/12/2022

... por perecimento, deterioração, roubo, furto ou extravio; f) erro fiscal no cálculo do percentual de redução da base de cálculo sobre o qual deveria incidir a alíquota do tributo (fls. 1-18).

O Estado de São Paulo apresentou impugnação, sustentando a higidez da autuação fiscal e da certidão de dívida ativa, a legalidade da regra de estorno do imposto creditado em relação a mercadoria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

SAF - Serviço de Anexo Fiscal

1004462-66.2018.8.26.0126 - lauda

Autos no 1004462-66.2018.8.26.0126

Embargante: Shibata Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral Ltda.

Embargado: Estado de São Paulo

SENTENÇA

Vistos.

1. Relatório:

Shibata Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral Ltda. opôs embargos à execução fiscal. Sustentou: a) a nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) por ser apócrifo, não contendo assinatura e número de matrícula do agente fiscal; b) a nulidade do AIIM por não constar recibo do auto de infração ou notificação por carta registrada com aviso de recebimento; c) nulidade da certidão de dívida ativa por englobar valores de diversos exercícios; d) itens de autuação com capitulação genérica, sem indicação específica, implicando cerceamento de defesa; e) haver direito de creditamento de ICMS em relação a mercadorias pagas e perdidas por perecimento, deterioração, roubo, furto ou extravio; f) erro fiscal no cálculo do percentual de redução da base de cálculo sobre o qual deveria incidir a alíquota do tributo (fls. 1-18).

O Estado de São Paulo apresentou impugnação, sustentando a higidez da autuação fiscal e da certidão de dívida ativa, a legalidade da regra de estorno do imposto creditado em relação a mercadoria entrada no estabelecimento e perda, e caber ao embargante o ônus da prova (fls. 78-101).

Houve réplica (fls. 756-757).

As partes pleitearam o julgamento antecipado (fls. 762-764 e 766).

É o relatório. Decido.

2. Fundamentação:

Tendo as partes declinado expressamente da produção de outras provas (fls. 762-764 e 766), promovo o julgamento antecipado.

Os embargos à execução não prosperam.

i) São insubsistentes as teses de nulidade do AIIM.

Observa-se que a abertura do procedimento fiscal foi realizada em meio eletrônico, com notificação (fls. 108-110) pelo Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), contando com confirmação da cientificação eletrônica do contribuinte em 29/01/2014 (fl. 110), assim como que o AIIM foi grafado por meio eletrônico (fls. 102-107).

Consta inclusive a identificação da Agente Fiscal de Rendas (fls. 107 e 110).

O artigo 34, inciso VII, da Lei nº 13.457/2009 dispensa que do AIIM conste o nome legível e a assinatura do Agente Fiscal de Rendas autuante quando grafado por meio eletrônico. Por sua vez, a comunicação eletrônica entre a SEFAZ e os contribuintes por meio do sistema de Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) tem amparo normativo na Lei nº 13.918/2009.

Utilizados o meio eletrônico e o DEC, não pode o AIIM ser considerado apócrifo e nem que tenha havido falha nas notificações do contribuinte.

ii) A certidão de dívida ativa pode englobar múltiplos exercícios.

Não existe obrigatoriedade legal de que para cada exercício exista um auto de infração e uma certidão de dívida ativa específica. Também não existe vedação legal de que múltiplos exercícios constem de CDA única.

O que a certidão de dívida ativa precisa conter é a descrição apropriada dos valores (artigo 2º, § 5º, inciso II, da Lei nº 6.830/80) e isto consta no presente caso, em que os valores devidos foram discriminados com clareza e com identificação individualizada do termo de referência do respectivo exercício mensal (fls. 46-53).

iii) Não se vislumbra vício de capitulação.

O embargante alegou (fl. 7) que na referência de 16/07/2014 consta capitulação genérica no artigo 214 do RICMS (terceiro quadro de fl. 50). Ocorre que o correspondente fato imputável (deixar de escriturar notas fiscais eletrônicas referentes a entradas de mercadorias no estabelecimento) foi descrito no AIIM (fl. 56), não se vislumbrando incongruência entre o fato e o dispositivo legal.

O posterior questionamento do embargante quanto ao respectivo item do AIIM (fls. 12-13) não colhe, na medida em que as operações correspondentes estão discriminadas no Demonstrativo 3 (fl. 61), com indicação das chaves de acesso para as notas fiscais.

Esses elementos eram suficientes a que o embargante exercesse o direito de defesa. Soma-se não ter comprovado no presente feito qualquer incongruência das chaves de acesso que impedisse a obtenção dos documentos e a conferência pelo contribuinte, o que atrai a aplicação da presunção de legitimidade e veracidade das informações lançadas pelo fisco no procedimento fiscalizatório.

O vício de escrituração não torna inviável a utilização do livro para autuação. Não se trata de documento inidôneo para extração dos fatos. Na verdade, é a própria falta de escrituração que consiste no descumprimento da obrigação tributária acessória e rende ensejo à aplicação de penalidade.

iv) Não há direito ao creditamento de ICMS em relação a mercadorias perdidas por perecimento, deterioração, roubo, furto ou extravio.

Embora entenda que é lógico e razoável o pensamento de que não deveria haver estorno dos créditos de ICMS em tais hipóteses, eis que as mercadorias foram pagas e se destinavam à venda, gerando oneração do contribuinte (que pagou pela entrada da mercadoria, deixou de ter o lucro com a venda ao consumidor e ainda perdeu o respectivo bem), essa medida dependeria de alteração legislativa. Enquanto não houver alteração, a lei deve ser aplicada, não cabendo ao juiz atuar como legislador positivo, o que vulneraria o princípio da separação de poderes.

E a legislação assinala a necessidade de estorno do imposto que o contribuinte tiver se creditado, conforme artigos 21, inciso IV, da Lei Complementar nº 87/1996; 41, inciso I, da Lei Estadual 6.374/89; e 67, inciso I, do RICMS.

O fundamento de creditamento por aplicação do princípio da não-cumulatividade (artigo 155, § 2º, inciso I, da Constituição) não encontra apoio, na medida em que a perda da mercadoria acarreta o fim do processo de circulação.

Sobre este tema, mais recentemente o Supremo Tribunal Federal não tem examinado o mérito de recursos, por entender que a matéria depende do reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via do recurso extraordinário (por exemplo: STF, ARE 902085/RJ, Relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento monocrático em 20/08/2015). No entanto, há antigo precedente com fundamento que ainda se sustenta em conformidade com o atual ordenamento jurídico-constitucional:

“ICM. PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA EXECUTADA E ULTERIORMENTE DESTRUÍDOS POR INCÊNDIO. A OBRIGATORIEDADE DO ESTORNO CORRESPONDENTE A ENTRADA NÃO INFRINGE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE (ART-23, II), UMA VEZ QUE O PERECIMENTO DAS MERCADORIAS, NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO DO COMERCIANTE, IMPORTA A RUPTURA DAS

ETAPAS DE CIRCULAÇÃO QUE COMPÕEM O CICLO DA TRIBUTAÇÃO." (STF, RE 105666, Primeira Turma, Relator Ministro Octavio Gallotti, julgamento em 08/11/1985).

v) Sobre o erro fiscal no cálculo do percentual de redução da base de cálculo sobre o qual deveria incidir a alíquota do tributo, a tese do embargante consiste em alegação de excesso de execução. Afirmou que os valores corretos do crédito de ICMS que deveriam ser estornados eram inferiores aos apurados pelo fisco, como exemplificou em uma mercadoria (fls. 17 e 757).

No entanto, consistem em requisitos legais para essa modalidade de alegação que tivesse sido declarado pelo embargante na petição inicial o valor que entendia como correto e que tivesse sido apresentado demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (artigo 917, § 3º, do CPC). Como assim não procedeu, a alegação de excesso de execução não pode ser examinada (artigo 917, § 4º, do CPC).

Observe em adição que: a) as regras do Código de Processo Civil são aplicáveis subsidiariamente à execução fiscal (artigo 1º da Lei nº 6.830/80); b) o cálculo do valor entendido como correto para o tópico era acessível ao embargante, quer diretamente (como feito em relação a um item nas fls. 17 e 757), quer mediante parecer técnico contábil; c) se os cálculos tivessem sido apresentados, pela extensão dos itens haveria necessidade de conferência por perícia judicial contábil, mas o embargante declinou de produzir outras provas (fl. 766); d) e o silêncio do embargado quanto à específica matéria por ocasião da impugnação não implica presunção de veracidade da tese do embargante, tanto por não incidir essa presunção em sede de embargos à execução (pois o embargado possui em seu favor um título executivo), quanto pela não incidência de efeitos de revelia sobre direito público indisponível (artigo 345, inciso II, do CPC), quanto pela ausência de valor declarado como controvertido para o tópico, quanto pela impugnação deduzida pelo embargado no sentido de presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos, cabendo ao embargante o ônus probatório (fls. 98- 100).

3. Dispositivo:

Diante do exposto:

a) Não conheço da tese de excesso de execução por erro fiscal no cálculo do percentual de redução da base de cálculo sobre o qual deveria incidir a alíquota do tributo.

b) Julgo improcedentes os embargos à execução quanto às demais matérias.

Em razão da sucumbência, condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor da procuradoria do embargado em montante equivalente a 10% do valor da causa (atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o ajuizamento em 10/07/2018, e com juros moratórios de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado).

Após o trânsito em julgado: a) traslade-se cópia desta sentença para a execução fiscal de origem; b) lá, expeça-se em favor da parte exequente mandado para levantamento do depósito contido na fl. 50 daquele feito.

Intime-se o Estado de São Paulo pelo portal eletrônico.

Publique-se. Intimem-se.

Caraguatatuba, 29 de dezembro de 2022.

Ayrton Vidolin Marques Júnior

Juiz de Direito